

1500891-70.2020.8.26.0187

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIO HENRIQUE GEBRAN SCHIRMER

Comarca: Fartura

Foro: Foro de Fartura

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... a aplicação da cláusula de 'tráfico privilegiado'. No ponto, destaque-se, especificamente, que acusado possui ocupação lícita (costureiro) e não existem indícios suficientes de que integre organização criminosa ou se dedique de maneira 'profissional', permanente e reiterada ao tráfico - situação a qual, por evidente, não descaracteriza o tráfico, mas, certamente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Fartura

Foro de Fartura

Vara Única

Rua Anacleto Gonçalves Neves, 250, Centro - CEP 18870-000, Fone: (14) 3382-1855,

Fartura-SP - E-mail: fartura@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500891-70.2020.8.26.0187

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2266347/2020 - DEL.POL.TAGUAI, 14353906 - DEL.POL.TAGUAI, 311/20/112 - DEL.POL.TAGUAI, 2266347 - DEL.POL.TAGUAI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL FRANKLIN NOGUEIRA FLORENTINO

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, nesta cidade e Comarca de Fartura, Estado de São Paulo, na sala virtual de audiência, presente o MM. Juiz de Direito desta Comarca, Exmo. Sr. Dr. Mário Henrique Gebran Schirmer, comigo Escrevente Técnico Judiciário, no final nomeado e assinado, aí, após os pregões legais, verificou-se o comparecimento do DD. Promotor de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Pedro Rafael Nogueira Guimarães, do réu Rafael Franklin Nogueira Florentino, acompanhado do seu defensor Dr. Adriano José Moreira de Melo; além da testemunha arrolada João Paulo de Sousa Lima. Instalada a audiência, com a presença do réu, pelo DD. Juiz foi inquerida a testemunha João Paulo de Sousa Lima, o que foi registrado conforme depoimento gravado em arquivo de vídeo, que será juntado aos autos, nos termos do artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004; do artigo 154, § 2º e artigo 279 ambos do

Código de Processo Civil; da Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça - C.N.J., artigo 2º e § 2º; do artigo 405, § 1º e 2º do Código de Processo Penal e demais corolários legais à espécie. Após, o réu foi interrogado, o que foi registrado conforme depoimento gravado em arquivo de vídeo, que será juntado aos autos, nos termos do artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004; do artigo 154, § 2º e artigo 279 ambos do Código de Processo Civil; da Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça - C.N.J., artigo 2º e § 2º; do artigo 405, § 1º e 2º do Código de Processo Penal e demais corolários legais à espécie. Em seguida, pelo MM. Juiz foi encerrada a instrução e perguntado às partes se havia algum requerimento de diligências, nos termos do artigo 402 do CPP, sendo que não houve qualquer requerimento, passando-se então aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, por ele foi feita a seguinte manifestação, o que foi registrado conforme depoimento gravado em arquivo de vídeo, que será juntado aos autos, nos termos do artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004; do artigo 154, § 2º e artigo 279 ambos do Código de Processo Civil; da Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça - C.N.J., artigo 2º e § 2º; do artigo 405, § 1º e 2º do Código de Processo Penal e demais corolários legais à espécie. A seguir, foi dada a palavra ao(à) Dr(a). Defensor(a) do réu, o que foi registrado conforme depoimento gravado em arquivo de vídeo, que será juntado aos autos, nos termos do artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004; do artigo 154, § 2º e artigo 279 ambos do Código de Processo Civil; da Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça - C.N.J., artigo 2º e § 2º; do artigo 405, § 1º e 2º do Código de Processo Penal e demais corolários legais à espécie. Posteriormente, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de RAFAEL FRANKLIN NOGUEIRA FLORENTINO, já qualificado nos autos, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06. A denúncia foi apresentada nos seguintes termos: "Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 27 de outubro de 2020, por volta das 7 horas, no interior do imóvel localizado na Avenida Apóstolo Bérnago, nº 867, Bairro Centro, nas imediações do estabelecimento de ensino Escola Municipal "Luiza Soldera Gobbo" e da Praça Pública Clementina, no município de Taguaí/SP, Comarca de Fartura/SP, RAFAEL FRANKLIN NOGUEIRA FLORENTINO, qualificado em fls. 6, tinha em depósito 2 (duas) porções contendo 5,14 g (cinco gramas e quatorze centigramas) de cocaína, para fins de venda e comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo apurado, os policiais civis João Paulo de Sousa Lima e Paulo Alexandre Torres, em cumprimento a mandado de busca e apreensão deferido nos autos 1500882-11.2020.8.26.0187 (fls. 27/29), encontraram no interior de uma caixa de metal vermelha, a qual estava no interior de um guarda-roupas do quarto do denunciado, 2 (duas) porções, acondicionadas em um invólucro plástico de cor branca, contendo 5,14 g cinco gramas e quatorze centigramas) de cocaína (laudo pericial em fls. 131/134), pertencentes a RAFAEL FRANKLIN NOGUEIRA FLORENTINO. Próximo da substância entorpecente, ainda foi encontrada uma balança de precisão, de cor cinza, sem marca aparente, medindo aproximadamente 12 cm X 6 cm (laudo pericial em fls. 127/130). No relatório de investigação (fls. 30/31), consta que há grande circulação de pessoas no local dos fatos, em movimentação típica do tráfico de drogas. Por fim, averiguou-se que o local dos fatos está localizado nas imediações da Escola Municipal "Luiza Soldera Gobbo" e da Praça Pública Clementina, cada qual alocada, respectivamente, a 17 (dezessete) e 28 (vinte e oito metros) do imóvel (laudo pericial em fls. 136/142). Os resultados das diligências prévias, as circunstâncias que envolveram a prisão, a quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, bem como a apreensão de petrecho empregado na partilha e embalagem da droga, comprovam a prática da traficância.". (fls. 153-154). A prisão em flagrante foi homologação e concedida liberdade provisória, com medidas cautelares diversas da prisão (fls. 50-54). Foi apresentado Recurso em Sentido Estrito (fls. 74; 86-91) contra a decisão, o qual foi julgado improcedente pelo e. TJ-SP (fls. 42-52, autos 0000906-16.2020 - em apenso). O acusado apresentou defesa prévia (fl. 162). A denúncia foi recebida na data de 31 de janeiro de 2022, não se

concedendo absolvição sumária e sendo determinada a realização de audiência de instrução e julgamento (fls. 170-172). Foi produzida a prova oral, com a oitiva da testemunha de acusação, bem como a inquirição do acusado, por meio de sistema de gravação audiovisual, em audiência realizada por videoconferência, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020. Encerrada a fase de instrução, o i. representante do Ministério Público, em sede de alegações finais, pleiteou a condenação do acusado, sustentando a comprovação dos fatos nos exatos termos em que narrados na denúncia. Argumentou que negativas as circunstâncias na pena base em razão da natureza da droga, devido o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, uma vez que comprovado que o local dos fatos é próximo a escola (fls. 137-142). Sustentou que indevida a minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, devida a imposição de regime fechado e incabível a aplicação do art. 44 e art. 77, da Lei 11.343/06. A Defesa da acusada pleiteou a sua absolvição em face da insuficiência probatória que cerca o lastro probatório contido nos autos, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postulou pela desclassificação da conduta ao art. 28, da Lei 11.343/06, alegando que inexistente prova da traficância. Subsidiariamente, postulou pela inaplicabilidade do art. 40, III, da Lei de Drogas, ao argumento de que a escola não estava em funcionamento, em razão da pandemia de coronavírus. Ademais, pugnou pela aplicação do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, fixação de regime aberto e substituição da pena. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 1. Inexistem alegações a respeito do trâmite processual e, tampouco, há, neste contexto, matéria a se conhecer de ofício, dado que o feito transcorreu regularmente. Por esta razão, é possível o julgamento do mérito da pretensão punitiva. 2. Antes, todavia, são necessários alguns apontamentos a respeito do standard probatório reclamado para a legitimação de uma condenação na seara penal. Afinal, a imposição de quaisquer penalidades pressupõe, para sua validade, não apenas o efetivo exercício de coerção, antes exigindo, também, que o poder estatal esteja assentado em premissas discursivas de legitimação (a respeito ver: FORST, Rainer. Justificação e Crítica – perspectivas de uma teoria crítica da política. São Paulo: Editora Unesp, 2018; ARENDT, Hannah. Sobre a Violência. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009). Trata-se, ao fim e ao cabo, da necessidade de justificação do poder, o que é inerente ao próprio conceito de democracia. Nesse contexto, a imposição de penas exige que o decreto condenatório esteja alicerçado em provas e fundamentos que conduzam a uma conclusão que se coloca além de um patamar de 'dúvida razoável' a respeito da existência e autoria delitivas. Neste sentido é a doutrina de Gustavo Badaró, ao afirmar que, conquanto a atividade probatória ambicione a reconstrução de fatos históricos – os quais, por evidente, não podem ser reproduzidos de maneira idêntica e absoluta –, nas hipóteses de procedência da pretensão punitiva deverá ser alcançada uma conclusão assentada em um "altíssimo grau de probabilidade" de ocorrência dos fatos tais como narrados na denúncia (BADARÓ, Gustavo. Ônus da prova no processo penal. São Paulo: Editora RT, 2003, p. 62). Isto se traduz, em síntese, em afirmar que a possibilidade de condenação está à mercê da maior ou menor solidez do contexto probatório que se está inserido, sendo, no entanto, necessário, sempre, um mínimo de lastro probatório para que se possa proferir um decreto condenatório. Feitas tais considerações gerais a respeito dos níveis probatórios necessários a comportar um decreto condenatório, passo ao exame dos elementos de prova existentes nos autos para atestar a comprovação, ou não, da prática do delito imputado à ré. 3. Analisando-se os elementos de informação, bem como a produção de provas em juízo, verifico que a materialidade e a autoria restam demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), auto de exibição (fls. 10), fotos (fls. 11-16), auto de constatação preliminar (fl. 17), laudos periciais (fls. 127-134; 136-142), bem como pela prova oral produzida em juízo. 4. A autoria está também demonstrada, pesando em desfavor do acusado, sobretudo pelos depoimentos apresentados em juízo e em fase policial. Nesse contexto, a testemunha João Paulo (investigador de polícia) relatou que, no final do ano de 2020, foram recebidas informações anônimas de que a pessoa de Rafael estaria vendendo cocaína em sua casa. Relatou que a residência do acusado é próxima a uma praça conhecida por ser ponto de uso de drogas e que realmente existia grande fluxo de pessoas na

residência do acusado. Diante das informações, realizaram campanhas e visualizaram que, efetivamente, havia um grande fluxo de pessoas no local, sendo possível notar que havia comercialização de produtos, pelo muro da casa do acusado, mas não era possível ver quais são as substâncias vendidas. Por esta razão, foi apresentado pedido de busca e apreensão. No cumprimento da medida, localizaram duas porções de cocaína e uma balança de precisão, tendo o acusado dito que a droga era para uso pessoal e a balança se destinava a pesagem de produtos de academia. Relatou, ainda, que a casa do acusado é próxima a uma creche, não recordando se a instituição estava aberta ao tempo dos fatos. Destaque-se que não foi possível a oitiva judicial da testemunha Paulo Alexandre (investigador de polícia), em razão de seu falecimento (fls. 175-176), mas seu relato, quando ouvido em fase policial (fl. 03), é absolutamente harmônico com as declarações de João Paulo em juízo. Em seu interrogatório, o acusado negou que seja traficante. Disse que a praça realmente é conhecida pela traficância, mas o delito é praticado por outra pessoa. Afirmou que fora usuário de drogas, mas tinha largado o vício, em razão da prática de musculação. Relatou que a droga era sua, mas para uso próprio. Disse que a balança de precisão era para utilização de produtos de musculação. Narrou que a movimentação de pessoas não era em sua casa, mas no vizinho, que fica a 01 metro de sua residência. Disse, ainda, que há uma árvore no local, que tampa a visão e, por isto, é possível confundir as casas. Relatou que não tinha problemas com os policiais. Afirmou que não vendia drogas, mas usava e a movimentação era em relação ao vizinho. Disse que a balança de precisão estava em seu armário, porque além de pesar suplementos também utilizava para pesar drogas que comprova fora da cidade de Taguaí.

5. 5. Diante deste contexto, autoria e materialidade estão, de maneira geral, comprovadas, conforme passo expor adiante. No ponto, ressalto, em primeiro lugar, que o policial narrou com clareza e de forma detalhada como se deram os fatos. Além disso, não há nos autos indícios de que ele tenha se manifestado de maneira maliciosa e temerária, imputando falsamente à prática criminosa a acusada. Ao contrário, o que se observa é que o agente público asseverou com precisão o desdobramento do fato, imprimindo certeza e seriedade em sua narrativa. Neste contexto, a jurisprudência, há muito, já firmou entendimento de que o testemunho dos policiais tem valor idêntico aos de outras pessoas que não possuam qualquer interesse no julgamento. Por todos, veja-se o posicionamento do e. Supremo Tribunal Federal: "VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência." (HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293). E, também, do STJ: "3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)." (AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)".

Nesse cenário, observe-se que os relatos confirmaram a pretensão punitiva descrita na inicial acusatória. Isto porque a narrativa apresentada pela testemunha é robusta, harmônica e verossímil, encontrando respaldo nas demais provas dos autos, em especial os laudos periciais e auto de apreensão das drogas. Ademais, observe-se que a negativa de traficância deve ser analisada na tipicidade - e não na comprovação de autoria e materialidade. Note-se o acusado confirmou que a droga em sua casa era de sua propriedade, negando, somente, que fosse destinada à

comercialização. Isto é, autoria e materialidade são incontestas, antes havendo controvérsia a respeito da tipicidade. Dessa maneira, entendo que estão comprovadas autoria e materialidade da conduta descrita na exordial. 6. Por esta razão, passa à análise do tipo penal. 6.1. Como se sabe, para a caracterização do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não se faz necessário que o acusado seja surpreendido no próprio ato da mercancia ilícita. Isto porque o tipo penal exposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, é um crime de núcleo misto e alternativo, para o qual basta a configuração de uma das condutas nucleares do tipo para que esteja comprovada a prática penal. Nesse sentido, observe-se a redação do art. 33, da Lei 11.343/06: "Art.33: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor a venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". (grifo nosso). In casu, a conduta do agente se ajusta aos verbos descritos no caput do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, haja vista que as provas dos autos demonstram, de maneira segura, que o acusado tinha em sua residência ("ter em depósito" e "guardar") as drogas apreendidas nos autos. 6.2. Quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, entendo ser cabível, dado que o acusado é primário (fls. 188-189), não ficou comprovado que se dedique a atividades criminosas e nem que integre organização criminosa, o que autoriza a aplicação da cláusula de 'tráfico privilegiado'. No ponto, destaque-se, especificamente, que acusado possui ocupação lícita (costureiro) e não existem indícios suficientes de que integre organização criminosa ou se dedique de maneira 'profissional', permanente e reiterada ao tráfico - situação a qual, por evidente, não descaracteriza o tráfico, mas, certamente, implica em diferenças, em relação aqueles que fazem do comércio ilegal de entorpecentes seu 'meio de vida'. 6.3. Ainda sobre a tipicidade, impropriedade a tese de desclassificação, ao art. 28, da Lei de Drogas, uma vez que as circunstâncias do caso (apreensão de balança de precisão, relato de diversas pessoas frequentando o local de maneira esporádica e rápida) evidencia a prática de tráfico. Note-se que o depoimento do policial foi inequívoco ao afirmar situações concretas de traficância e os demais dados objetos do caso confirmam a situação, especificamente o fato de que o acusado possuía, em seu armário, uma balança de precisão. Ainda no ponto, nota-se que absolutamente inverossímil a versão apresentada pelo acusado, sobretudo a respeito da balança de precisão. Afinal, não é possível assumir como verdadeira a tese de que a balança se destinasse a pesar suplementos, quando estava guardada em seu armário, no quarto. 6.4. Incabível a imposição da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06, dado que não comprovada a situação de aplicabilidade da norma. Isto porque para a caracterização da causa de aumento não basta a prática do delito próximo a localidade mencionada no art. 40, III, da Lei de Drogas (escola), sendo imprescindível demonstrar que o ilícito se direcionava aos frequentadores do estabelecimento. No ponto, não se olvida de dissídio jurisprudência sobre o tema a respeito da circunstância ser ou não de natureza objetiva. No entanto, não se pode ignorar que a incidência de causas de aumento tem em vista a maior reprovabilidade das condutas e para que a situação esteja caracterizada é necessário que se demonstre a vinculação entre o local de traficância e o estabelecimento que legitimaria o aumento da pena. Nesse sentido, uma compreensão do art. 40, III, da Lei de Drogas, que desconsidere a necessidade de vinculação entre o local e a prática do ilícito, invariavelmente conduziria a situações infirmam a própria norma, não se demonstrando a maior reprovabilidade do comportamento. Além disso, a despeito da divergência jurisprudencial da aplicabilidade em 'tempos ordinários', os tribunais têm apresentado entendimento consolidado no sentido de que durante a pandemia de Covid-19, em razão do fechamento das escolas, é indevida a aplicação do art. 40, III, da Lei 11.3043/06. Por todos, veja-se julgado do e. TJ-SP: "Apelação da Defesa - Tráfico de Drogas - Provas suficientes à condenação - Materialidade e autoria comprovadas - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Apreensão de diversas porções de maconha e de cocaína em poder do réu - Depoimentos harmônicos dos policiais

militares responsáveis pela abordagem – Negativa do acusado isolada do contexto probatório – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas – Condenação mantida – Pena-base fixada em 1/6 acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes – Circunstância agravante da reincidência bem reconhecida – Afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da mesma norma – Não comprovada a existência de estabelecimento de ensino e de recreação nas proximidades do local dos fatos – Crime praticado em período de férias escolares e de suspensão das aulas presenciais, havendo presunção da completa desocupação do prédio – Inexistência de prova em sentido contrário, de incumbência do órgão acusador – Pena ajustada – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, ante a recalcitrância criminal – Impossibilidade da modificação do regime prisional com base no período de prisão preventiva – Questão que deve ser analisada pelo Juízo da execução – Recurso de apelação parcialmente provido.”

(TJSP; Apelação Criminal 1500996-26.2021.8.26.0603; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/02/2022; Data de Registro: 25/02/2022) 7. A respeito dos demais elementos dos injustos penais, observa-se que o acusado é imputável, tem a consciência da ilicitude de suas ações, lhe era exigível conduta diversa e não agia amparado por causa excludente de ilicitude, devendo, então, responder pelas ações praticadas, dado que todos os elementos da estrutura analítica dos delitos estão presentes. 8. Ante o exposto, restou claramente demonstrado que a acusada RAFAEL FRANKLIN NOGUEIRA FLORENTINO realizou a conduta típica e antijurídica, subsumível ao tipo penal indicado no art. 33, §4º da Lei 11.343/06. 9. Passo à dosimetria da pena. O crime previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/06 apresenta pena abstrato de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias multa. 9.1. Na análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do CP, não foi possível valorar a conduta social e o comportamento da vítima, a personalidade da agente, em razão da ausência de elementos informativos a respeito de tais vetores. Ainda, os motivos e as circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal. A culpabilidade é neutra, na medida em que as circunstâncias inerentes ao caso em análise são comuns à espécie. O acusado é primário (fls. 188-189). Em relação ao crime de “tráfico de drogas”, o art. 42 da Lei 11.343/06, estabelece, como circunstâncias preponderantes no contexto da análise da primeira fase da dosimetria, a ponderação da natureza e quantidade de drogas. In casu, a quantidade de drogas, não deve ser sopesada nessa etapa, mesmo que a quantidade não seja desprezível, essa se encontra consonância com os padrões ordinários verificados na prática. Em contrapartida, a natureza da droga deve ser analisada negativamente, uma vez que se tratam de duas substâncias entorpecentes distintas, sendo uma delas (cocaína) capaz de gerar gravíssimos danos à saúde e implicar em forte dependência química, conforme consenso na comunidade científica. Desta maneira, conforme o exposto acima exaspero a pena base, de modo que fixo a pena provisória em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. 9.2. Passo à segunda fase da dosimetria. Neste momento, analisam-se as circunstâncias agravantes e atenuantes. Nesta fase, não se verifica a presença de nenhuma circunstância agravante ou atenuante da pena, motivo pelo qual mantenho inalterada a reprimenda anteriormente fixada, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. 9.3. Na terceira fase da dosimetria analisam-se as causas de aumento e diminuição. In casu, não se vislumbra nenhuma causa de aumento a ser considerada nesta fase. Em contrapartida, conforme exposto acima, devida a aplicação da norma disposta no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, tendo em vista que o acusado é primário e não ficou suficientemente demonstrado que se dedique de maneira permanente às atividades ilícitas ou integre organização criminoso. No ponto, ressalto que a benesse deve ser considerada em seu patamar médio (1/2), sopesando as circunstâncias do caso concreto (balança de precisão, diversas pessoas frequentando o local de maneira esporádica e rápida). Sendo assim, tais fatos impõe a aplicação do privilégio no patamar relatado. Pelo exposto, fixo a pena definitiva em 03 (três) anos de

reclusão, bem como ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa. 9.4. Tendo em vista o quantum de pena aplicado e a primariedade do agente, nos termos do art. 33, §2º, do CP, fixo o regime ABERTO para o início de cumprimento de pena. Fixa-se o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, nos termos da tabela do TJ-SP, uma vez que não há nos autos informações que permitam arbitramento em outro valor. 9.5. A despeito da redação do art. 44, da Lei de Drogas, adotando entendimento consolidado nos tribunais superiores, entendo possível a substituição de pena no caso em análise, em razão do quantum de pena aplicado e o preenchimento dos demais requisitos previstos no art. 44 do CP. Assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em: (i) prestação de serviços à comunidade (art. 43, IV), na razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser determinada pelo juízo da execução, com realização preferencial aos finais de semana ou outro horário que não atrapalhe o labor do acusado; e (ii) no pagamento de prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, nos termos da tabela do TJ-SP. 9.6. Em razão da substituição, inviável a aplicação do art. 77, do CP. Diante do exposto, considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória, para CONDENAR a acusada RAFAEL FRANKLIN NOGUEIRA FLORENTINO, devidamente qualificada, à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, por considera-lo como incurso no crime previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06. Entretanto, nos termos do art. 44 do CP, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, por duas restritivas de direito, consistentes em: (i) prestação de serviços à comunidade (art. 43, IV), na razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser determinada pelo juízo da execução, com realização preferencial aos finais de semana ou outro horário que não atrapalhe o labor da ré; e (ii) no pagamento de prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, nos termos da tabela do TJ-SP. Permanece aplicável ainda a supracitada reprimenda de 300 (trezentos) dias-multa, uma vez que apenas a pena privativa de liberdade é passível de substituição. Custas pelo acusado, na forma da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada eventual gratuidade que lhes sejam deferidas. Considerando que a sentença não tem o condão de alterar de maneira imediata a situação processual da parte, mantenho a situação em relação as cautelares, nos termos da decisão de fls. 105-108. Serve a presente decisão como ofício/mandado/intimação. Nos termos do art. 50-A, da Lei 11.343/2006, DETERMINO a incineração das drogas apreendidas, sendo tomadas as devidas cautelas legais. Diante do contexto da apreensão do dinheiro e dos bens, nos termos do art. 61, da Lei 11.343/06, entendo que comprovado que os valores são provenientes do tráfico e, por esta razão, declaro seu perdimento. Fixo honorários no valor de 100% da tabela do convenio OAB/Defensoria, em favor da defensora. Expeçam-se as guias e certidões necessárias. Após o trânsito em julgado: i. Comunique-se a Justiça Eleitoral, para fins do art. 15, III, da Constituição Federal; ii. Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do artigo 686, do Código de Processo Penal; iii. Oficie-se ao I.I.R.G.D., noticiando desta condenação. iv. Oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação do réu; v. Expeça-se guia de execução penal. Publique-se. Registre-se. Intime-se." Cientificados da sentença, o Representante do Ministério Público e o Patrono do réu pediram a vista dos autos, o que lhes foi concedido. Saem os presentes intimados".2.- se houver testemunhas da DeNada mais havendo, foi encerrada a audiência, lavrando este termo, que lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, MARIANA COSTA MARTINELLI, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA